

1500384-38.2021.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167098/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 18614745 - DEL.POL.BATATAIS, 1389/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2167098/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 2167098 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500384-38.2021.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-38.2021.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167098/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 18614745 - DEL.POL.BATATAIS, 1389/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2167098/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 2167098 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

JOSÉ FÂNIO OLIVEIRA e DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de junho de 2021, por volta de 8h50min, na Rua José Munari, 361, bairro Parque Semielli, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mantinham em depósito e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de: 19,570 (dezenove gramas e quinhentos e setenta miligramas) de crack, em uma única porção, embalada em material plástico preto; 1,490g (um grama e quatrocentos e noventa miligramas) de cocaína, distribuída em duas porções, acondicionada em material plástico preto; 32,530g (trinta e dois gramas e quinhentos e trinta

gramas) de maconha, distribuída em 7 (sete) porções de tamanhos diversos, sendo duas a granel e cinco embaladas em material plástico, substâncias estas que causam dependência física e psíquica.

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04).

Boletim de Ocorrência (fls. 16/19).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21).

Em decisão de fls. (66/68) foi convertida a prisão em flagrante do réu Diego Rodrigues dos Santos em prisão preventiva.

Laudo Pericial (fls. 83/85 e 320/322).

Em decisão de fl. (98) foi decretada a prisão preventiva do réu José Fânio Oliveira.

Citados (fl. 97) os réus apresentaram a defesa preliminar, Diego às fls. 159/160 e José à fl. 168.

A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2021 (fls. 172/173).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, por último, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 285/289).

A Defesa do réu José Fânio, por seu turno, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugnou pelo reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas, com a fixação em seu redutor máximo, bem como pela fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena (fls. 293/304).

Já a Defesa de Diego requereu pela absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, do Código de Processo Penal (fls. 306/311).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 16/19), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), pelo Laudo Pericial (fls. 83/85 e 320/322), bem como pela prova oral coligida.

A autoria dos réus também restou demonstrada.

Interrogado em juízo, o réu Diego Rodrigues dos Santos negou a prática da traficância no local. Disse que é usuário de drogas e não estava na residência de José Fânio quando os policiais lá chegaram, mas sim na casa ao lado, consignando que tinha ido encontrar com sua ex-mulher. Conta que realmente estava com duas porções de cocaína no bolso e que esta seria destinada ao seu consumo. Afirma que não conhece José Fânio e nunca vendeu drogas. Ao ser questionado sobre a versão apresentada em solo policial, o declarante assevera que desconhece o teor do quanto ali consignado.

Interrogado em juízo, o réu José Fânio Oliveira também negou a prática da traficância. Disse que nesse dia estava em casa dormindo e escutou um barulho no portão, ocasião em que saiu da residência e viu a polícia. Admitiu que realmente saiu correndo porque tinha droga no interior da casa para consumo. Relata que estava guardando a pedra de crack para outra pessoa em troca de dinheiro, já que tem dívida por drogas. Assevera que nunca nem viu Diego. Saliência que a balança, os saquinhos e a faca era para cortar, pesar e embalar a pedra de crack, porque todo dia o indivíduo passava e pegava uma porção.

Em juízo, a testemunha Nilton César de Oliveira, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando receberam informações, via CAD, acerca de uma denúncia anônima, dando conta que dois indivíduos estariam "batendo drogas", ou seja, preparando entorpecentes para comercialização. Acrescenta que na denúncia foram indicados os nomes dos indivíduos e o endereço. Ao chegarem no local, os policiais visualizaram pelo portão da casa, que estava entreaberto, os acusados manipulando as drogas. Percebendo a presença dos milicianos, relata que os acusados empreenderam fuga pelo fundo do imóvel, pulando muros, sendo que somente o corréu Diego foi contido. Esclarece que, em busca pessoal, lograram êxito em encontrar duas porções de cocaína e, ao voltarem para a residência, foram apreendidas o

restante das drogas, além de embalagens e uma balança de precisão. Assevera que ambos são bem conhecidos nos meios policiais. Questionado, consignou que adentrou no imóvel após a abordagem do corréu Diego, acompanhado da cunhada deste, isso porque se tratava de uma circunstância envolvendo flagrante delito. Também ouvida em juízo, a testemunha Larissa Guimarães Dossi, policial militar, corroborou o depoimento de seu colega de farda. Acrescentou que visualizaram os acusados manipulando uma substância, aparentando ser maconha, pelo portão, que estava parcialmente aberto. Contou que, após a contenção de Diego, o Cabo Oliveira vistoriou o imóvel, acompanhado da cunhada dele, encontrando porções de crack e maconha, faca com resquício da droga, saquinhos para embalar e balança de precisão. Ratificou o fato de os acusados serem conhecidos dos meios policiais. Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação dos acusados. Não se demonstrou que os policiais militares tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente, imputarem aos acusados a prática de um crime tão grave.

Sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade".(TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos agentes mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo, discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Outrossim, deve ser ressaltado que os milicianos ouvidos foram uníssonos em afirmar que visualizaram ambos os acusados dentro da residência manipulando os entorpecentes, fato que infirma a versão exculpatória trazida pelos réus em Juízo, mormente a do acusado Diego, que, de forma divergente da declaração prestada em solo policial, afirmou que não estava na residência de José Fânio quando os policiais lá chegaram.

Cumpra também salientar que, a despeito da alegação do acusado de que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização e sem mandado judicial, tal ingresso é válido e regular.

Com efeito, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, traz a proteção ao domicílio, tornando-o inviolável, senão vejamos:

"XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"

Portanto, durante o dia, é possível o ingresso em domicílio nas seguintes hipóteses: com o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou mediante determinação judicial. Durante a noite, o ingresso em domicílio alheio só pode ocorrer nos seguintes casos: com o consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Como acima transcrito, uma das hipóteses em que é permitido o ingresso em domicílio alheio são nas situações de flagrante delito. Ora, dos autos consta que na residência do corréu José Fânio foram encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas.

O crime de tráfico de drogas é peculiar, pois algumas de suas condutas correspondem a crimes permanentes, cuja consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a

qualquer momento. Dessa forma, quem, por exemplo, guarda ou tem em depósito determinada quantidade de droga em sua residência está continuamente em flagrante delito.

E considerando a exceção trazida pelo próprio dispositivo constitucional a respeito da inviolabilidade do domicílio, conclui-se que o armazenamento de drogas em determinada residência admite a entrada de agentes policiais independentemente de autorização judicial.

Não se pode olvidar que, in casu, havia fundadas suspeitas de que no interior da residência do citado acusado estaria ocorrendo o flagrante delito, diante da denúncia anônima informada, além da situação em que os réus foram abordados, havendo fundada suspeita de que estariam manipulando drogas, conforme se infere dos relatos dos policiais, que assim o observaram pela porta entreaberta.

Dessarte, observo, portanto, que a conduta está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Este é, inclusive, o entendimento do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"Habeas corpus" Tráfico de drogas Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente Não acolhimento Ausência de constrangimento ilegal Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" Crime permanente Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente Precedentes Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Quanto ao mais, para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico tutelado saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, ainda que houvesse a ausência de flagrante dos atos de comércio, esta seria absolutamente irrelevante para a efetiva caracterização da traficância imputada aos réus. Para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, a lei não exige qualquer ato de comércio e, da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito.

Vale consignar, ainda, que a quantidade e a forma como a droga estava acondicionada - 19,570g (dezenove gramas e quinhentos e setenta miligramas) de crack, em uma única porção; 1,490g (um grama e quatrocentos e noventa miligramas) de cocaína, distribuída em duas porções; e 32,530g (trinta e dois gramas e quinhentos e trinta gramas) de maconha, distribuída em 7 porções de tamanhos diversos, sendo duas a granel e cinco embaladas em material plástico, aliado aos objetos apreendidos - uma faca com resquícios de maconha, balança de precisão e embalagens plásticas - revelam a intenção de venda dos acusados, demonstrando que as drogas se destinavam ao consumo de terceiras pessoas, não sendo o caso de desclassificação para o crime de uso.

Deste modo, cabais e indúvidas tanto a materialidade, quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Quanto ao réu JOSÉ FÂNIO OLIVEIRA:

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente encontrada. Assim, verifica-se que a conduta do acusado é de maior gravidade, considerando que seriam destinados a inúmeros usuários, razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima de seu mínimo legal, ou seja, 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Presente a atenuante da menoridade relativa. Não há agravantes a serem consideradas. Assim, nesta fase, resta a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Observo não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que impossibilita a aplicação do redutor. Aliás, insta ressaltar que o réu responde por outro processo, também relativo ao tráfico de drogas, bem como que os policiais informaram que ele já era muito conhecido pela traficância, o que corrobora a tese de envolvimento com o meio ilícito.

Fixo, para o cumprimento da pena, o regime inicial fechado, tendo em vista gravidade concreta do delito, já que os réus foram flagrados preparando quantidade relevante de drogas para a comercialização.

Entendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da suspensão condicional da pena, diante do montante de pena fixado.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: ("...

APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP - Impossibilidade - Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas - ..." - HC 2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Quanto ao réu DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS:

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente encontrada. Assim, verifica-se que a conduta do acusado é de maior gravidade, considerando que seriam destinados a inúmeros usuários.

Outrossim, verifico que o acusado é reincidente (fls. 199/201), vez que possui mais de uma condenação já transitada em julgado, sendo que uma delas será utilizada para fins de reincidência e a outra para fins de configurar os maus antecedentes. Desta forma, fixo a pena-base em 1/3 acima de seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Presente a agravante da reincidência, conforme se depreende de fls. 208/209, razão pela qual majoro a pena em 1/6, resultando em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Observo não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante a expressiva quantidade de droga apreendida e a reincidência, o que impossibilita a aplicação do redutor.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista as referidas circunstâncias judiciais, a reincidência e a quantidade da pena.

Diante a quantidade de pena fixada, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como inviável a concessão de "sursis".

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais

outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: (“... APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP – Impossibilidade – Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas – ...” – HC 2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR:

a) JOSÉ FÂNIO OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e;

b) DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Não permito o apelo dos acusados em liberdade, mormente, agora, que se concluiu pela responsabilização criminal. Ademais, persistem os motivos que autorizaram as decretações das prisões preventivas dos acusados. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Determino, outrossim, a incineração da droga apreendida, reservada a porção necessária à eventual contraprova, nos termos do art. 58, § 1º, do aludido diploma legal.

Custas pelos acusados, no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a gratuidade de justiça.

Diante da constituição de novos patronos pelo réu Diego, como se depreende do instrumento procuratório juntado à fl. 245, deverá a serventia realizar as pertinentes retificações no SAJ.

Sem prejuízo, em virtude do trabalho desenvolvido pela patrona indicada pelo Convênio OAB/Defensoria Pública (fl. 62), arbitro os honorários dela em 60% da tabela do referido convênio. Expeça-se a certidão de honorários e, decorrido o prazo de sua impressão, exclua-se o nome desta do sistema digital.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; expeçam-se guias de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Batatais, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA